

BOLETIN No. 01.2 DEL 2019 .-

SANCIONADA LA LEY DE FINANCIAMIENTO 1943 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018... CONOZCA LAS NORMAS QUE INTERESAN AL SECTOR NO LUCRATIVO - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.-

La ley 1943 del 2018 trae consigo la siguiente estructura:

TÍTULO I.- MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EN IMPUESTO A LAS VENTAS E IMPUESTO AL CONSUMO.

Capítulo i.- impuesto sobre las ventas

Capítulo ii .- impuesto nacional al consumo

TÍTULO II.- NORMAS DE FINANCIAMIENTO EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES

TÍTULO III.- NORMAS DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO, NORMALIZACIÓN Y DIVIDENDOS

Capítulo i.- impuesto al patrimonio

Capítulo ii .- nuevo impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio

Capítulo iii.- impuesto a los dividendos para sociedades nacionales

TÍTULO IV.- MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y EL ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA

Capítulo i.- impuesto sobre la renta y complementarios

Capítulo ii.- establecimientos permanentes

Capítulo iii.- entidades controladas del exterior

Capítulo iv.- fondos de capital privado

Capítulo v.- entidades sin ánimo de lucro

Capítulo vi.- otras disposiciones

Capítulo 12 .- de la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria

TÍTULO V .- NORMAS DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Capítulo i.- impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple

Capítulo ii .- régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional

Capítulo iii.- régimen de compañías holding colombianas (chc) en el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales

Capítulo iv.- obras por impuestos

Capítulo vi.- impuesto sobre la renta para personas jurídicas

Capítulo vi.- gravamen a los movimientos financieros

TÍTULO VI.- OTRAS NORMAS PARA AUMENTAR EL RECAUDO A TRAVÉS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN

Capítulo i.- procedimiento tributario

TÍTULO VII.- DISPOSICIONES FINALES

VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.-

ADVERTENCIA PRELIMINAR:

Es importante conocer la estructura precedente de la nueva ley de financiamiento, en lo que hace referencia a los temas que regula, habida cuenta de hacer comprensible el alcance de sus modificaciones frente al sector no lucrativo y en concreto en las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen especial de tributación. Por esa razón hemos creído oportuno desarrollar nuestro análisis y compartirlo con ustedes, bajo la estructura de cuestionamientos claves que en el marco de las actividades de este sector muchas entidades podrían preguntarse. Para facilitar la lectura y el análisis del documento, este se compone de dos partes. Esperamos que sean de la mayor utilidad posible.

A continuación presentamos los interrogantes claves:

1. La venta de bienes inmuebles por parte de entidades sin ánimo de lucro está gravada con el IVA?.-
2. Que debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente al tratamiento de los servicios de alimentación institucional o a empresas prestados bajo contrato (catering)?
3. Que obligaciones surgen en las entidades sin ánimo de lucro cuando contraten servicios gravados con el IVA cuando los mismos sean prestados desde el exterior?

4. Las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder al régimen simple de tributación?
5. Que obligaciones adquiere una entidad sin ánimo de lucro cuando contrata con una persona natural y/o jurídica que está registrada en el régimen de tributación simple?
6. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse a los incentivos de Zonas Zomac que creó la ley 1819 del 2016 y al beneficio de Obras por Impuestos nuevamente regulado por la nueva ley de financiamiento?
7. Si una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial es responsable del IVA, por prestación de servicios, estos son gravados en todos los casos?
8. Que aspectos debe tener en cuenta una entidad sin ánimo de lucro frente a la obligación de la factura electrónica?.
9. Una entidad sin ánimo de lucro que pertenezca al régimen tributario especial, debe tener en cuenta la modificación que introdujo la ley de financiamiento al artículo 90 del ET?
10. En qué casos una entidad sin ánimo de lucro puede perder los beneficios del régimen tributario especial y que efectos se pueden presentar frente a ese hecho?
11. Es requisito legal para que una entidad sin ánimo de lucro que quiera ser admitida en el régimen tributario especial, se obligue a realizar los aportes parafiscales y cotizaciones de ley?
12. Una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial puede llevar como egreso procedente las contribuciones pagadas para educación de sus empleados o miembros del grupo familiar del trabajador y en general los pagos a las inversiones en educación?
13. Una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Impuesto Extraordinario de Patrimonio creado por la ley de financiamiento para los años 2019, 2020 y 2021?
14. Cuando una entidad sin ánimo de lucro contrata con personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia o sociedades extranjeras, servicios, comisiones, arrendamientos, consultorías, regalías por conceptos de ingresos gravados en Colombia, debe practicar retención en la fuente a título de renta y a que tarifa?
15. Por efecto de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 sufrió algún cambio el régimen del descuento tributario por donaciones a entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial de que trata el artículo 257 del ET?
16. Cual es el tratamiento fiscal de las erogaciones por concepto de tributos pagados por las entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen especial en desarrollo de la actividad meritoria?

17. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse al incentivo tributario creado para las empresas de Economía Naranja por la nueva ley de financiamiento?

18. A partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, una entidad sin ánimo de lucro puede sustentar sus actuaciones ante la DIAN con base en un concepto emitido por dicho organismo?

SEGUNDA PARTE .- ANALISIS Y RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS NUEVE (9) A DIECIOCHO(18).-

9. Una entidad sin ánimo de lucro que pertenezca al régimen tributario especial, debe tener en cuenta la modificación que introdujo la ley de financiamiento al artículo 90 del ET?

El artículo 90 del ET regula la determinación de la renta bruta en la enajenación de activos. Con la nueva disposición se amplía su título para referirse al valor comercial en operaciones de bienes y servicios. El resultado de la renta bruta tanto en la normatividad anterior como en la nueva continúa siendo el mismo, la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo enajenado.

La norma mantiene el tratamiento concreto cuando se trate de activos depreciables y advierte que el saldo constituye la renta o ganancia ocasional según el caso. Importante recordar que las entidades sin ánimo de lucro no están sometidas al régimen de ganancias ocasionales. Tanto en la norma anterior como en la nueva el precio de enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie; solo que en la nueva norma se aclara que el valor comercial de las especies recibidas forma parte del precio de enajenación.

De la misma manera la regulación mantiene el criterio de indicar como lo hacía la norma anterior, que se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual deberá corresponder al precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. En la nueva norma se hace explícita la previsión para los servicios.

En el entorno tributario de las entidades sin ánimo de lucro es bien sabido de la intención del legislador para controlar los pagos a vinculados (artículo 356-1 del ET)¹ en el sentido que si bien pueden realizarse, estos podrán hacerse a precio comercial promedio. Este concepto ya se definió en la normatividad reglamentaria del DR 2150 del 2017², muy en la línea de lo normado por el nuevo artículo 90 del ET, en cuyo caso podríamos afirmar que

¹ Fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o a entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control.

² Ver artículo 1.2.1.5.1.39 del DR 2150 del 2017.

las entidades sin ánimo de lucro ante todo deben observar la normativa que les es especial y al observarla de paso están ajustándose al mandato del artículo 90 del ET en la parte de la definición del precio comercial promedio.

Con ocasión de los análisis realizados desde la oficina a la normatividad tributaria de las entidades sin ánimo de lucro con ocasión de la expedición de la ley 1819 del 2016, del DR 2150 del 2017 y del Concepto Unificado 481 del 2018, advertíamos que no entendimos la razón por la cual habiendo tomado las referencias del artículo 90 del ET para definir el precio comercial promedio a tener en cuenta para el mandato del artículo 356-1 del ET, se guardó silencio respecto de la normativa que esa misma disposición legal traía cuando se trataba de venta de bienes raíces, en la cual no se aceptaba un valor inferior al costo, al avalúo catastral vigente o a la auto avalúo.

Desde nuestra perspectiva seguimos pensando que si una entidad sin ánimo de lucro estando calificada en el régimen tributario especial vende un bien raíz, debe respetar dicha normatividad y ahora con mayor razón los nuevos controles que impone la ley de financiamiento. Nos referimos a:

- ✓ En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al auto avalúo, sin perjuicio de la posibilidad de un valor comercial superior. En los casos en que existan listas de precios, bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de los bienes raíces enajenados o transferidos, los contribuyentes deberán remitirse a los mismos. Del mismo modo, el valor de los inmuebles estará conformado por todas las sumas pagadas para su adquisición, así se convengan o facturen por fuera de la escritura o correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como aportes, mejoras, construcciones, intermediación o cualquier otro concepto.
- ✓ En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción las partes deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá informarse el precio convenido en ellos. En la misma escritura se debe declarar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para determinar el valor real de la transacción.

- ✓ Los inmuebles adquiridos a través de fondos, fiducias, esquemas de promoción inmobiliaria o semejantes, quedarán sometidos a lo previsto en esta disposición. Para el efecto, los beneficiarios de las unidades inmobiliarias serán considerados como adquirentes de los bienes raíces, en relación con los cuales deberá declararse su valor de mercado.

10. En qué casos una entidad sin ánimo de lucro puede perder los beneficios del régimen tributario especial y que efectos se pueden presentar frente a ese hecho?

Justamente este es el único tema que expresamente se trata en la nueva ley de financiamiento en lo que hace referencia a las normas del régimen tributario especial. Ya lo habíamos comentado con anterioridad habida cuenta de la divulgación de un boletín interno de finales del 2018 publicado en la página de la oficina.

Se trata de la modificación del artículo 364-3 del ET realizada por el artículo 62 de la nueva ley. A continuación transcribimos los únicos apartes de la norma anterior que se modifican, para a renglón seguido transcribir el cambio:

- ✓ Inciso 2 del Parágrafo 1 del artículo 364-3 de ET antes de la nueva ley.- Las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial pasados tres (3) años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto.
- ✓ Inciso 2 del Parágrafo 1 del artículo 364-3 del ET después de la nueva ley.- Las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial para el año gravable siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto.

Como puede apreciarse, en relación con el segundo inciso el cambio sustancial que se propone se relaciona con que en la normatividad actual si la entidad sin ánimo de lucro es excluida, solamente puede retornar al régimen especial pasados tres (3) años desde su exclusión; lo que siempre nos produjo la sensación de un viso de inconstitucionalidad de la norma³; ahora con el proyecto, las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial para el año gravable siguiente a la pérdida del mismo; con lo cual no tendrán que esperar tres años para volver al régimen.

³ Pero aún más compleja la situación cuando la ley define un tiempo de exclusión del régimen especial de tres (3) años, pasado el cual la entidad podría volver a solicitar la calificación para ser nuevamente admitida en el régimen especial, lo que significa en términos reales una sanción al impedir el desarrollo de su actividad social con un viso de inconstitucionalidad al principio de la libertad de empresa. En definitiva si además de la exclusión, se aplica un régimen ordinario de tributación, la entidad estaría siendo sancionada dos veces por un mismo hecho, situación que quebranta el principio constitucional formulado bajo la premisa de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.

- ✓ Parágrafo 4° del artículo 364-3 del ET antes de la nueva ley.- La administración tributaria deberá proferir mediante acto administrativo debidamente motivado la decisión respectiva sobre la cual procederán los recursos de reposición y apelación. Mientras el acto administrativo correspondiente no se encuentre en firme, la entidad mantendrá su calidad de entidad sin ánimo de lucro sometida al Régimen Tributario Especial.
- ✓ Parágrafo 4 del artículo 364-3 del ET después de la nueva ley.- En caso de pérdida de los beneficios del régimen tributario especial, dichos beneficios se tornan improcedentes a partir del año gravable en que se incumpla con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial.

En relación con este parágrafo, anotamos el texto propuesto es consistente con el pretendido cambio en el sentido que la entidad sin ánimo de lucro, al perder su beneficio y por tanto excluirse del régimen especial, puede volver a dicho régimen a partir del año siguiente al que esto ocurra, es decir al año siguiente a la pérdida del mismo y no esperar a los tres (3) años de que habla el régimen actual.

Lo otro que anotamos del nuevo texto del parágrafo 4 es que se suprime la regulación del derecho de defensa y debido proceso que debía darse frente a el acto administrativo al que se refiere la norma actual. Pensamos que en definitiva, salvo en el caso del sector cooperativo cuya regulación actual se mantiene (parágrafo 3), la intención del Gobierno es la de suprimir el acto administrativo que enerva el proceso de discusión para en su lugar simplemente entender que la pérdida de los beneficios del régimen especial se materializa con ocasión del proceso normal de revisión de la declaración tributaria, dentro del cual obviamente se le concede a la entidad sin ánimo de lucro su derecho de defensa y debido proceso.

11. Es requisito legal para que una entidad sin ánimo de lucro que quiera ser admitida en el régimen tributario especial, se obligue a realizar los aportes parafiscales y cotizaciones de ley?

Sí. Con la incorporación del artículo 118 de la ley de financiamiento que modifica el parágrafo 2o del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: PARÁGRAFO 2. Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7o de la Ley 21 de 1982, los artículos 2o y 3o de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1o de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

Es suficientemente ilustrativo y claro que este requisito es indispensable como condición previa a la calificación de una entidad sin ánimo de lucro al régimen tributario especial.

12. Una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial puede llevar como egreso procedente las contribuciones pagadas para educación de sus empleados o miembros del grupo familiar del trabajador y en general los pagos a las inversiones en educación?

Si es posible llevar como de egreso procedente estos pagos. Aspecto que resulta novedoso por el artículo 77 de la nueva ley de financiamiento, solo que la operatividad de la deducción queda atada al reglamento. El texto de la nueva norma se transcribe a continuación:

Adiciónese el artículo 107-2 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:

ARTÍCULO 107-2. Deducciones por contribuciones a educación de los empleados. Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas.

- a) Los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y de créditos condonables para educación, establecidos por las personas jurídicas en beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador;
- b) Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y/o de educación inicial, para niños y niñas menores de siete años, establecidos por las empresas exclusivamente para los hijos de sus empleados;
- c) Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación básica- primaria y secundaria -y media reconocidas por el Ministerio de Educación, y las de educación técnica, tecnológica y de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, y que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos, los pagos definidos en este artículo no se considerarán pagos indirectos hechos al trabajador.

Lo anterior será reglamentado por el Gobierno Nacional.

13. Una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Impuesto Extraordinario de Patrimonio creado por la ley de financiamiento para los años 2019, 2020 y 2021?

En efecto la ley de financiamiento creó el citado impuesto y lo incorporó al ET en el artículo 292-2 y siguientes, razón por la que se justifican las derogatorias expresas de las normas que venían contenidas en el ET. Estableció la ley los nuevos sujetos pasivos, dentro de los cuales se aprecia en la nueva normatividad la intención del legislador por gravar únicamente a las personas naturales nacionales y extranjeras, a diferencia de las regulaciones anteriores del impuesto donde igualmente se gravaban las personas jurídicas

salvo la excepciones que la norma misma establecía. En el caso de la versión impuesto de patrimonio 2019 no se gravan las personas jurídicas, salvo las sociedades y entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros.

Habida cuenta de lo anterior se justifica la derogatoria expresa de los artículos 297 y 297-1 del ET. En conclusión las entidades sin ánimo de lucro no están sujetas al impuesto de patrimonio creado por la nueva ley de financiamiento.

Al margen de lo anterior recomendamos que al interior de las entidades sin ánimo de lucro se revise la información del RUT porque nos hemos encontrado con casos donde en dicha información está indebidamente registrado el código 40 como si la entidad estuviera sometida al impuesto de patrimonio en la versión de las vigencias anteriores.

14. Cuando una entidad sin ánimo de lucro contrata con personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia o sociedades extranjeras, servicios, comisiones, arrendamientos, consultorías, regalías por conceptos de ingresos gravados en Colombia, debe practicar retención en la fuente a título de renta y a que tarifa?

Lo primero para reiterar es que en materia de retenciones a título de renta, como lo indicamos en la respuesta a la pregunta No. 5, la entidad está en la obligación de practicar las retenciones en la fuente a que haya lugar dependiendo del concepto del pago, en razón a que no existe norma que las exima de asumir el rol tributario de agentes de retención.

En este caso concreto es importante indicar que la nueva ley de financiamiento en su artículo 86 modificó el régimen tarifario de las rentas de capital y de trabajo cuando las mismas sean pagadas o abonadas en cuenta a favor de los beneficiarios indicados en la formulación de la pregunta. En efecto el nuevo artículo 108 del ET, determina una nueva tarifa de retención del 20%, aumentando con ello en 5 puntos porcentuales la tarifa vigente hasta la expedición de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018.

15. Por efecto de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 sufrió algún cambio el régimen del descuento tributario por donaciones a entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial de que trata el artículo 257 del ET?

El descuento tributario por donaciones no sufrió cambio alguno por la nueva ley de financiamiento, razón por la cual siguen vigentes las disposiciones anteriores tanto a nivel de ley como de reglamento al igual que la doctrina oficial generada con ocasión del cambio vertida en el concepto unificado DIAN 481 del 2018.

El régimen de descuentos en la nueva ley ciertamente tuvo un cambio importante, fruto del cual se deriva el texto del artículo 84 que modificó el artículo 259-2 del ET al eliminar a partir del año gravable 2019 todos los descuentos tributarios aplicables al impuesto sobre la renta, que sean distintos de los contenidos en los artículos 115, 254, 255, 256, 257 Y 258-1 del Estatuto Tributario, el artículo 104 de la Ley 788 de 2002 y los previstos en esta Ley para las ZOMAC. Nótese que el descuento del artículo 257 mantuvo su vigencia.

En relación con esta norma la modificación está en la adición de un párrafo al texto inicial del artículo 257, cuyo texto incorporado por la ley 1943 del 2018 transcribimos y se explica por sí solo: Todos los usuarios de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia tendrán la posibilidad de efectuar donaciones para el financiamiento y sostenimiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas⁴ a través de los cajeros automáticos, páginas web y plataformas digitales pertenecientes a dichas entidades financieras, quienes emitirán los certificados de donación a fin de que los donantes puedan tomar el descuento tributario en los términos previstos en los artículos 257 y 258 del Estatuto Tributario. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN mediante resolución reglamentará lo dispuesto en este artículo.

16. Cual es el tratamiento fiscal de las erogaciones por concepto de tributos pagados por las entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen especial en desarrollo de la actividad meritoria?

Este es un interrogante que viene desde la respuesta que la DIAN dio frente a algunos cuestionamientos a través del Concepto Unificado 481 del 2018. En su momento la DIAN indicó: Así las cosas, los impuestos, tasas y contribuciones pagados por las entidades del Régimen Tributario Especial, se exceptúan de las limitaciones del Título I del Libro Primero del Estatuto Tributario. Esta situación no sólo cubre el desarrollo de actividades meritorias, sino también las complementarias, pues ambas generan los ingresos que luego de detraerse los egresos, serán objeto de reinversión en la actividad meritoria.

Nuestras apreciaciones en el nuevo marco de la ley de financiamiento frente a este aspecto se derivan del cambio que introdujo al artículo 115 del ET por efecto del artículo 76. De la nueva norma rescatamos:

- (i) Se mantiene la deducción pero en forma más amplia pues se refiere la norma a impuestos, tasas y contribuciones, los que en su conjunto integran el concepto de TRIBUTOS;
- (ii) Se abre la posibilidad a la deducibilidad de todos los tributos pagados y que tengan relación de causalidad con la actividad económica, salvo el caso del impuesto de renta;

⁴ Queda clara la restricción del beneficio SOLAMENTE para este tipo de instituciones.

- (iii) Se mantiene la deducibilidad del GMF en el 50% (al 100% a partir del 2022),
- (iv);
- (iv) Aspecto novedoso, se le permite al contribuyente (opción) tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros;
- (v) Se permite la deducibilidad de las cuotas de afiliación pagadas a los gremios.

Vistos los cambios en el caso de las entidades sin ánimo de lucro anotamos:

Sigue vigente la disposición especial del DR 2150 del 2017 en virtud de la cual se permite la deducción de los TRIBUTOS efectivamente pagados en desarrollo de la actividad meritoria, lo cual significa que dicha procedencia del egreso también cubre el 100% del GMF y el pago del impuesto sobre la renta, dado que la norma reglamentaria exceptúa a estas entidades de la limitación del 115 incorporada al título I del Libro I del ET.

17. Una entidad sin ánimo de lucro puede acogerse al incentivo tributario creado para las empresas de Economía Naranja por la nueva ley de financiamiento?

Este incentivo tributario está previsto en el numeral 1 del artículo 79 de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, norma que modificó el artículo 235-2 del ET. Y consiste básicamente en que las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, serán exentas del impuesto de renta por un término de siete (7) años, siempre que se cumplan los requisitos de los literales a) a g) de la norma. Al dar lectura de ellos observamos que la intención del legislador es otorgar el beneficio a las personas jurídicas que se constituyan antes del 31 de diciembre del 2011 bajo la forma jurídica societaria (literales a), b), d) y f)), las cuales además deberán desarrollar alguna de las actividades que la misma ley califica y codifica (literal c).

Observamos que algunos de los códigos que allí se mencionan pueden corresponder a las actividades de cultura que el artículo 359 del ET contempla como meritorias para pertenecer al régimen tributario especial⁵. Sin embargo como se trata de cumplir la totalidad de los requisitos, en nuestra opinión el hecho de que las entidades sin ánimo de lucro participen en esencia jurídica de una naturaleza no societaria, ese hecho descarta de plano la posibilidad de acogerse al incentivo creado por la ley de financiamiento. Por otra parte desde una mirada puramente práctica, creemos que una entidad sin ánimo de lucro que esté calificada en el régimen tributario especial por desarrollar algunas de las actividades que citamos en la nota 8 de pie de página, de suyo ya tiene el beneficio d ela

⁵ Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Actividades especializadas de diseño. Actividades de fotografía. Creación literaria. Creación musical. Creación teatral. Creación audiovisual. Artes plástica y visuales. Actividades teatrales. Actividades de espectáculos musicales en vivo. Otras actividades de espectáculos en vivo. Actividades de bibliotecas y archivos.

exención del impuesto de renta y no tendría mucho sentido pensar en acogerse a uno nuevo que en estricto sentido lo es posible acceder.

18. A partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, una entidad sin ánimo de lucro puede sustentar sus actuaciones ante la DIAN con base en un concepto emitido por dicho organismo?

El artículo 264 de la ley 223 de 1995, norma que permitía a los contribuyentes sustentar sus actuaciones en vía gubernativa y contenciosa con base en conceptos de la DIAN, siempre y cuando los mismos estuvieren vigentes y no hubieren sido revocados mediante publicación en el Diario Oficial⁶, fue derogado expresamente por la nueva ley de financiamiento. Esto significa por una parte que a partir del 1 de enero del 2019 se pierde el derecho de los contribuyentes, entre ellos el de las entidades sin ánimo de lucro, a soportar sus actuaciones con base en la doctrina de la DIAN; de hecho el artículo 113 de la ley de financiamiento indica que los contribuyentes solo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la Ley, lo cual significa que la administración tributaria tendrá libertad para objetar las actuaciones de los contribuyentes, siempre y cuando las mismas vayan en contra de la normatividad, habida cuenta que los conceptos que la DIAN emita constituyen interpretación oficial para los empleados públicos. Contrario a lo advertido por algunos estudiosos de esta materia, pero desde luego respetando su postura, pensamos que mantiene vigencia y relevancia jurídica la interposición de demandas de nulidad sobre los conceptos de la DIAN, puesto que al fin de cuentas si existe un fallo de nulidad de su contenido en su totalidad o de algunos apartes, estos efectos deben ser respetados por los empleados públicos de la administración tributaria.

JUAN CARLOS JARAMILLO DIAZ.

j.jaramillo@jpabogados.co

www.jpabogados.co

⁶ Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo.